

1500816-87.2020.8.26.0621

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Walter Emídio da Silva

Comarca: Guaratinguetá

Foro: Foro de Guaratinguetá

Vara: 4ª Vara

Data de Disponibilização: 20/01/2022

... DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. PRISÃO EM FLAGRANTE. ENTRADA EM DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. CRIME PERMANENTE.

TJ-SP - Revisão Criminal RVCR 22072409020218260000 SP 2207240- 90. 2021. 8. 26. 0000 (TJ-SP jurisprudência•Data de publicação: 25/10/2021 Revisão criminal -

Tráfico de entorpecentes - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guaratinguetá

Foro de Guaratinguetá

4ª Vara

Avenida Ariberto Pereira da Cunha, 280, Portal das Colinas - CEP 12516-410, Fone: (12) 3125-4133, Guaratinguetá-SP - E-mail: guarat4@tjsp.jus.br

SENTENÇA

Processo nº:

1500816-87.2020.8.26.0621 - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Carlos Andre de Oliveira Rosa e outro

CONCLUSÃO

Aos 06 de dezembro de 2021, faço estes autos conclusos ao MM. Juiz de Direito da 4ª Vara, DR. WALTER EMÍDIO DA SILVA.

Eu, Walter Emídio da Silva, digitei.

VISTOS OS AUTOS.

CARLOS ANDRÉ DE OLIVEIRA ROSA e SANDRO WALLACE SILVA MACHADO, qualificados nos autos, foram denunciados, como incursos nas penas do artigo 33, "caput", artigo 35, "caput", c.C. O 40, inciso IV (emprego de arma de fogo) todos da Lei n. 11.343/06 e artigo 16, § 1º, inciso IV da Lei 10826/2003, na forma do artigo 29 e 69 do Código Penal, porque, no dia 09 de outubro de 2010, por volta de 19 horas e 20 minutos, na Avenida Integração, 595, Rua 9, bl. 122, Vila Guarã, nesta cidade e comarca, agindo previamente associados e em concurso e com unidade de desígnios e identidade de propósitos, traziam consigo e guardavam, para fins de consumo de terceiros, 21 (vinte e um) pinos eppendorfs contendo cocaína e 45 (quarenta e cinco) porções de Cannabis Sativa L, substâncias estas causadoras de dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou

regulamentar, que foram devidamente apreendidas e periciadas. Consta ainda, que os acusados também agindo em concurso e total adesão de vontades, portavam um revólver, marca Taurus, calibre 38, de uso permitido, com a numeração suprimida, municiada com 06 cartuchos intactos, bem como mais seis cartuchos integros de munição calibre 38, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

Os réus foram devidamente notificados e apresentaram suas respostas a acusação (fls.241/217 e 249/244).

A denúncia foi recebida à página 254/255.

Em audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas 02 (duas) testemunhas arroladas pela acusação e interrogado os réus. A pedido da defesa, foi deferido a substituição dos depoimentos por apresentação de memoriais (FLS. 285/286).

Em alegações finais (fls. 291/298), o Doutor Promotor de Justiça, postulou a procedência da ação penal nos exatos termos da denúncia.

A defesa do réu Sandro Wallace Silva Machado, em alegações finais (fls. 299/309), requereu a sua absolvição, alegando ausência de provas para a prática do crime de tráfico ilícito de substância entorpecente. Requereu, ainda, absolvição do Réu do crime imputado de associação para o tráfico, por ausência de prova da existência do fato. Requereu, ainda, caso entenda-se pela condenação, que seja aplicada ao Réu a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4 °, da referida Lei de Drogas, com a consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. A defesa do réu Carlos André de Oliveira Rosa, em alegações finais (fls. 313/322), alegou, preliminarmente, Invasão de Domicílio, sem consentimento do morador, com afronta ao artigo 5 °, inciso XI da C.Federal. Ao final pediu a devolução dos objetos apreendidos durante a invasão de domicílio. Aduziu que o réu é confesso, no que diz respeito ao artigo 33 da Lei de Drogas, "mas era primeira vez que estava vendendo, devido a necessidade de alimentar a si e a sua família". Pediu a absolvição, no que diz respeito ao crime de associação ao tráfico, previsto no artigo 35 da Lei de Drogas, sob a alegação de que não há prova do elemento subjetivo do tipo, o dolo associandi. Salientou que o acusado foi confesso na posse irregular de arma de fogo. No entanto, asseverou que as munições de calibre 38 não lhe pertenciam. Aduziu que o auto de exibição e apreensão, descreve como arma apreendida um revólver calibre 22", enquanto que a denúncia fala em revólver calibre 38". No entanto as munições de calibre 38" foram retiradas da casa do acusado de forma arbitrária, devendo ser desentranhada dos autos. Argumento que a conduta tipificada no inciso IV do artigo 40 (emprego de arma de fogo) da Lei 11343/2006, constitui um verdadeiro "bis in idem". Pediu o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da lei 11.343/2006. Postulou o reconhecimento do direito de apelar em liberdade. Reconhecimento da atenuante da menoridade relativa.

É o relatório.

FUNDAMENTO.

Cuida a espécie presente de denúncia oferecida em razão de crime de tráfico dito praticado pelos Réus que teriam se associado para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, e, agindo em concurso e unidade de desígnios e identidade de propósitos, estariam trazendo e guardando, para fins de consumo de terceiros, 21 (vinte e um) pinos contendo cocaína, e 45 (quarenta e cinco), porções de Cannabis Sativa L, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Consta também a denúncia que os acusados, agindo em concurso e total adesão de vontades, portavam um revólver, marca Taurus, calibre 38", de uso permitido e numeração suprimida, devidamente municiado com seis cartuchos intactos, bem como mais seis cartuchos integros de munição 38, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

A preliminar sustentada pela defesa do acusado Carlos André, alegando invasão de domicílio, não prospera. Em primeiro lugar os acusados estavam em situação de flagrância e em segundo lugar , por se tratar de crime permanente, desnecessário a apresentação de mandado judicial e de consentimento do proprietário do imóvel. Neste sentido:

STJ - HABEAS CORPUS HC 455544 RS 2018/0151518-5 (STJ) Jurisprudência•Data de publicação: 24/09/2019HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. PRISÃO EM FLAGRANTE ENTRADA EM DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. CRIME PERMANENTE. DESNECESSIDADE DE MANDADO JUDICIAL. INDÍCIOS PRÉVIOS DA SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. CUSTÓDIA PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE, VARIEDADE E NATUREZA DELETÉRIA DAS DROGAS APREENDIDAS. PERICULOSIDADE DO AGENTE. REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 2. O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça - STJ consolidou-se no sentido de que o crime de tráfico de entorpecentes na modalidade "guardar" é do tipo permanente, cuja consumação se protraí no tempo, o qual autoriza a prisão flagrante no interior do domicílio, inclusive no período noturno, independente de mandado judicial, desde que precedida por investigação que indique sua necessidade, o que ocorreu no caso concreto. 3. No caso dos autos, verifica-se que foi constatada a existência de indícios prévios da prática da traficância, o que autoriza a atuação policial, não havendo falar em nulidade da prisão em flagrante no interior do domicílio do agente, por ausência de mandado judicial. 4. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP . Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP . 5. A prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, evidenciadas pela variedade, quantidade e natureza deletéria das drogas localizadas - 36 pinos de cocaína, 12 buchas de maconha e 47 pedras de crack -, circunstâncias que, somadas à apreensão de dinheiro e 2 aparelhos celulares, demonstram risco ao meio social. Ademais, é certo o risco de reiteração delitiva, tendo em vista que o paciente conta com uma condenação anterior pela prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico e outras 2 por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Nesse contexto, recomenda-se a manutenção da segregação antecipada, para garantia da ordem pública. 6. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 7. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 8. Habeas corpus não conhecido. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. PRISÃO EM FLAGRANTE. ENTRADA EM DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. CRIME PERMANENTE.

TJ-SP - Revisão Criminal RVCR 22072409020218260000 SP 2207240- 90. 2021. 8. 26. 0000 (TJ-SP jurisprudência•Data de publicação: 25/10/2021 Revisão criminal - Tráfico de entorpecentes - Ilegalidade na busca domiciliar realizada pelos policiais militares - Violação de domicílio - Inocorrência - A entrada em domicílio alheio, para a viabilização de prisão em flagrante, não viola o aludido princípio constitucional -Flagrante de crime permanente, situação que torna prescindível o mandado judicial - Absolvição e redimensionamento da reprimenda - Não conhecimento - Revisão conhecida em parte e indeferida na parte conhecida". Destarte, indefiro os requerimentos formulado pela defesa dói acusado Carlos André de Oliveira Rosa.

Quanto ao mérito, no que diz respeito à materialidade do delito de tráfico de drogas, observamos que as substâncias entorpecentes foram constatadas como sendo realmente as drogas em questão, qual seja cocaína e Cannabis Sativa L, prévia e

definitivamente, de acordo com o Auto de Constatação de Substância Entorpecente/Toxicológico (fls. 46/49) e Laudo Pericial - lei 11.343/2006 (fls. 147/149). Do mesmo modo, a materialidade do crime de porte ilegal de arma, vem comprovada pelo laudo inserto em fls. 177/180.

A autoria, por sua vez, é igualmente certa e indubitosa a partir do que nos autos consta, como veremos linhas a seguir.

Os acusados foram interrogados em duas oportunidades, na polícia e em juízo. Na polícia optaram pelo silêncio.

Em Juízo, o acusado Carlos asseverou que realizava o tráfico drogas, por necessidade. Disse que precisava de R\$ 100,00 (cem reais), para completar o pagamento de uma conta da família. Aduziu que já possuía R\$ 400,00 (quatrocentos reais). Salientou que pediu os R\$ 100,00 emprestado a uma pessoa. Aduziu que esta pessoa ofereceu-lhe o dinheiro em troca da venda de entorpecentes. Afirmou que no exato momento em que servia o corréu Sandro, foi abordado pela polícia. Relatou que foi preso e autuado em flagrante delito.

O acusado Sandro, roborando a versão apresentada pelo acusado Carlos, ao ser interrogado em Juízo, asseverou que foi preso e autuado em flagrante no exato momento em que recebia a droga de Carlos. Aduziu que foi a primeira vez que comprou droga do acusado Carlos.

A versão apresentada pelo acusado Carlos e roborada pelo acusado Sandro não encontrou ressonância na prova dos autos.

Assim é que, o policial Jeferson Eduardo Castro de Oliveira, ouvido sob o crivo do contraditório, asseverou que no dia dos fatos, juntamente com o seu colega de farda Fábio, realizava patrulhamento pelo residencial Santa Mônica. Disse que avistaram dois indivíduos. Disse que se aproximaram deles. Aduziu que o acusado Carlos dispensou uma sacola plástica e um revólver calibre 22", com a numeração suprimida. Salientou que o acusado foi revistado e com ele encontrado a importância de R\$ 45,00. Ressaltou que no interior da sacola dispensada foram encontrados 20 pinos de cocaína e 33 trouxas de maconha. Sustentou que a arma também foi apreendida. Disse que Sandro Wallace foi abordado por seu colega Fábio. Aduziu que em revista pessoal foi encontrado com ele sete trouxas de maconha, R\$ 119,00 em dinheiro, mais R\$15,60 em moedas e um aparelho celular. Salientou que ambos os acusados confessaram informalmente que estavam realizando o tráfico de droga. Afirmaram que faziam o tráfico de droga para se sustentarem. Relatou que o acusado Carlos disse que a arma era para proteção pessoal ante os concorrentes do Residencial Flamboyant. Disse que na casa do acusado Sandro, foram encontradas cinco trouxas de maconha e um pino de cocaína. Asseverou que na casa do acusado Carlos foram encontradas seis munições de calibre 38, uma balança de precisão e R\$ 400,00 em dinheiro. Aduziu que Carlos confessou que o dinheiro era produto do tráfico. Informou que os acusados já eram conhecidos nos meios policiais. Narrou que os acusados já foram abordados em outras oportunidades. Disse que os acusados eram vistos sempre juntos.

A testemunha Fábio Samuel da Silva, policial militar, ouvido sob o crivo do contraditório, confirmou integralmente a versão apresentada por seu colega de Farda, Jeferson Eduardo Castro.

Como se vê, a prova dos autos é firme e coesa no sentido de que os acusados se dedicavam ao tráfico ilícito de entorpecentes, como meio de vida.

Tanto é verdade que os acusados, ao serem abordados pelos milicianos, confessaram informalmente a eles que estavam praticando o tráfico de drogas, para o próprio sustento.

Vale lembrar que as afirmativas feitas pelo agente policial têm a presunção "juris tantum" de serem verdadeiras, posto que está à serviço do Estado para garantir a segurança do cidadão e manter a ordem pública, cabendo a quem alegar eventual falsidade ou conduta ilícita da parte dele, prová-la ou, ao menos, trazer ao juízo indícios coerentes da dita irregularidade, o que não aconteceu no presente caso.

Neste sentido:

"Quanto ao depoimento de policiais, presume-se que agem eles no cumprimento do dever e nos limites da legalidade, havendo que se repudiar sua palavra somente quando em flagrante dissonância com os demais elementos de convicção trazidos ao

processo." (TJSP, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Devienne Ferraz, votação unânime, RT 727/473).

Começamos pela análise do delito tipificado no artigo 33 "caput", da Lei n. 11.343/06 do Código Penal.

Assim, observa-se que o referido delito restou devidamente caracterizado e os seus Autores corretamente identificados.

Primeiramente, cumpre observar que o crime de tráfico, previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/06 possui natureza múltipla, ou seja, sua tipificação descreve mais de uma conduta, em relação à mesma vítima, que neste caso é a saúde pública. Essa classificação é de suma importância, pois o tráfico não consiste em apenas no ato de vender drogas a alguém.

Nota-se que o policial militar foi categórico ao dizer que encontrou as drogas descritas na exordial com os acusados, que informalmente confessaram a prática do tráfico.

Igualmente, o depoimento vem em conformidade com o que foi apreendido, de acordo com o Auto de Exibição e Apreensão às páginas (fls.36/38).

Seria um contrassenso, portanto, acreditar nas versões desconexas da realidade e desprovidas de qualquer prova apresentada pelos acusados e simplesmente desprezar o depoimento do agente policial, posto que este está a serviço do Estado para garantir a segurança do cidadão e manter a ordem pública.

Deste modo, observo que as características da traficância pelos Réus restaram devidamente comprovadas.

Assim, as alegações das Defesas, em que pese a elogiável apurada técnica dos Doutores Defensores, caem no vazio e em nada alteram a certeza sobre a dinâmica dos fatos e a verdade delituosa ora analisada.

Importante lembrar que, conforme é de sabença geral, os agentes policiais não existem para "caçar" aquelas pessoas que não possuem bons antecedentes, existem, sim, para combater a ilicitude e manter a ordem pública.

Neste sentido, vejamos o que preceituado pela Carta Magna de 1988:

Art. 144 - A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:

- I - polícia federal;
- II - polícia rodoviária federal;
- III - polícia ferroviária federal;
- IV - polícias civis;
- V - polícias militares e corpos de bombeiros militares.

(...)

§ 5º Às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública; aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil.

Assim sendo, impossível os policiais militares terem perseguido os acusados simplesmente por mera opção e tentativa de pegar um inocente.

Quanto à tipicidade tenho que é a exata correlação dos fatos de que se ocupa este processo à norma penal invocada na exordial, pouca coisa resta para dizer, já que o acontecido se ajusta perfeitamente à situação criada em abstrato pelo legislador penal, senão vejamos:

Art. 33 - Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

Pena - reclusão, de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos, e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Exatamente o que aconteceu no caso, pois nenhuma dúvida há sobre a conduta ilícita dos Réus, consoante documentos e testemunhos carreados ao bojo dos autos.

Vale ressaltar, ademais, que a substância entorpecente que os acusados traziam

consigo e guardavam, pela razoável quantidade e forma de acondicionamento (21 pinos preenchidos com cocaína e quarenta e cinco (45) porções de maconha), denota, já por si, que se destinava ao comércio ilícito e, pois, ao consumo de terceiros. Cabe observar, nesse passo, que a apreensão de razoável quantidade de substância entorpecente em poder dos agentes, além da circunstância de estar separada em unidades diferentes e ou semelhantes, conduz à segura conclusão de que se destinava ao comércio ilícito e não ao uso próprio, como tem proclamado reiteradamente a jurisprudência.

CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARTA FINS DE TRÁFICO- Artigo 35 " caput" da Lei 11.343/2006. Também é indubitável que os réus estavam associados (artigo 35 "caput" da Lei 11.343/2006)..

Os acusados foram flagrados em plena traficância, na via pública, os quais juntos forneciam drogas aos usuários e recebiam o valor correspondente, tanto que tinham sob suas posses certa quantia em dinheiro e moedas. Ao serem abordados pelos policiais tentaram se evadir, mas foram impedidos. O comportamento dos acusados demonstra que eles estavam associados à prática delitiva da traficância.

No passado muito se discutia acerca do crime de associação e do concurso de agentes.

Com a edição da Lei 11.343/2006, as controvérsias que existiam com referência ao crime de associação para fins de tráfico foram dissipadas, ou seja, "os elementos gramaticais ou literais do artigo 14 da Lei n. 6.368/76 eram e são claros, ou seja, dever-se-ia punir a associação eventual e não eventual, uma vez prevista, como elemento do tipo, a locução "reiteradamente ou não".

O artigo 18, inciso III da Lei acima referida, também estabelecia causa de aumento de pena em razão da mesma circunstância.

Destarte, indiscutível que eram normas conflitantes.

Assim, objetivando compatibilizar tais normas passou-se a interpretar o artigo 14 da Lei 6.368/76, tal qual o crime de quadrilha, exigindo-se estabilidade e permanência para o tráfico de drogas.

Com o advento da Lei 11.343/06 esse quadro normativo sofreu mudanças, uma vez que foi revogada a causa de aumento de pena prevista no regime anterior (Artigo 18, III), o que se deu com o único propósito de se resolver o conflito de normas acima mencionado, ou seja, aquele havido entre os artigos 14 e 18, III, da Lei 6.368/76. Com o novo regime, não há motivo para se ignorar os elementos do tipo penal albergado no Artigo 35 da Lei 11.343/06, em especial, a locução "reiteradamente ou não", pois, o que não é reiterado somente pode ser eventual e o que é eventual não exige estabilidade de permanência.

Reforça esse entendimento a descrição típica do artigo 35 parágrafo único, que estabeleceu um tipo especial de associação, qual seja, a associação destinada ao financiamento do tráfico de drogas.

Nesse tipo penal, ao contrário do que exige o "caput", a exigência literal que a associação seja reiterada, ou seja, a associação para o financiamento do tráfico de drogas exige inequivocamente estabilidade e permanência, ao passo que a associação para o tráfico de droga poderá ser eventual.

A conclusão ainda se robustece quando atentamos para a pena em abstrato cominada para o financiamento para o tráfico de drogas, que já equivale as penas de tráfico e associação somadas sem prejuízo, a despeito da clareza dos elementos do tipo e do óbvio propósito de se sanar um conflito anterior de normas, a doutrina pátria continua a dar a mesma interpretação para o artigo 35 da lei 11.343/06, ou seja, continua a exigir estabilidade ou permanência não prevista no tipo penal.

Na realidade, o crime de quadrilha ou bando, nada tem a ver com a associação prevista no artigo 35 da Lei 11.343/06.

O artigo 35 estabelece que basta a associação reiterada ou não, para a prática do tráfico de drogas, ou seja, basta a associação eventual para a prática de um delito de tráfico de drogas para configuração do crime .

Não se exige, em momento algum, a exemplo do crime de quadrilha ou bando, que os agentes se reúnam para a prática de crimes, ou seja, para a prática de mais de um crime.

Quisesse a lei excluir o alcance do artigo 35 "caput", a simples co-autoria para o

tráfico também o teria feito claramente deixando de consignar a expressão "ou não". Entretanto assim, não agiu o legislador, inarredável a conclusão de que o concurso eventual de agentes para traficância se amolda ao artigo 35 caput da lei 11.343/06".

Como se vê, os elementos de prova coligidos para os autos são mais do que suficientes para alicerçar um decreto condenatório.

PORTE ILEGAL DE ARMA (ARTIGO 16, § 1º, inciso IV da Lei 10.826/2003.

Quanto ao porte ilegal de arma de fogo, tanto a autoria quanto a materialidade estão perfeitamente comprovadas nos autos. No entanto, para evitar a ocorrência do "bis in idem", será considerado como causa de aumento de pena do artigo 40, inciso IV (emprego de arma de fogo) da Lei 11.343/2006, porquanto, no caso dos autos, nota-se que a arma apreendida com os Acusado estava sendo utilizada para o fim específico do comércio ilícito de entorpecentes, como processo de intimidação difusa ou coletiva, havendo, portanto, nexos finalístico entre as condutas de portar arma de fogo e aquela relativa ao tráfico.

Assim, é de se aplicar a pretendida causa especial de aumento de pena prevista no inciso IV (emprego de arma de fogo) do artigo 40 da Lei nº 11.343/2006 em substituição à condenação pelo crime do artigo 16, § 1º, inciso IV da Lei nº 10.826/2003, uma vez que restou demonstrado nos autos que o delito de tráfico de drogas foi praticado com o emprego arma de fogo.

Assim, comprovadas as autorias, as materialidades delitivas e inexistindo causa de exclusão da ilicitude, a ação penal é procedente, não merecendo prosperar as teses defensivas esposadas as fls. 299/309 e 313/322).

Posto isso, passo a dosar a pena aplicável à espécie, com base nos artigos 59 e 60 do Código de Penal.

I - PENA-BASE

Considerando e atendendo à culpabilidade dos Réus, tenho que não se revestem os fatos praticados de reprovabilidade anormal ou exacerbada, tendo o dolo sido regular ao tipo; aos seus antecedentes, observo que os Réus não possuem; à conduta social, não se tem nos autos elementos para aferi-la, uma vez que diz respeito tão-só à forma com que os Réus se relacionavam com seus pares no meio em que vivem; à personalidade, igualmente não se dispõe de elementos capazes de traduzir a estrutura psíquica dos Réus; aos motivos do crime, não há especificação quanto aos motivos que os levaram ao delito, possivelmente o lucro fácil, mas tal motivação não é alheia aos delitos do gênero, razão pela qual deixo de considerar essa circunstância em desfavor dos Réus; às circunstâncias do crime, respeitante estas, não há nada que refuja à normalidade desse tipo de delito; às consequências do crime de tráfico, são de extrema gravidade, principalmente para os próprios Réus, contudo, tais consequências são inerentes aos delitos dessa natureza, e às consequências do crime, não escapam à normalidade em casos da natureza; e, finalmente, quanto ao comportamento das vítimas, saliente-se que ela em nada contribuiu para esse tipo de conduta delituosa, aliás, a coletividade é que é a titular do bem jurídico protegido (saúde pública). Deixo, portanto, de considerar esta circunstância.

Assim, ante a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo suas penas-bases dos réus em seu mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e a multa pecuniária em 500 (quinhentos) dias-multa para o delito tipificado no artigo 33 "caput" da Lei n. 11.343/06, sendo cada dia-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do maior salário-mínimo (art. 43 da Lei n. 11.343/06) e 03 (três anos de reclusão e 700 (setecentos dias-multa), para o crime tipificado no artigo 35 "caput" da Lei 11.343/2006.

II - PENA PROVISÓRIA

Passo à análise das agravantes e das atenuantes e fixação da pena provisória, neste sentido, observo que os Réus não as possuem, ficando as suas respectivas penas inalteradas por ora.

III-PENA DEFINITIVA

Nos termos do artigo 40, inciso IV da Lei 11.343/2006, os crimes foram praticados com emprego de arma de fogo. Assim, para o delito tipificado no artigo 33 "caput" da Lei n. 11.343/06, fixo a pena privativa de liberdade em cinco anos e dez meses

de reclusão e a pena pecuniária em 583 (QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS), DIAS-MULTA e para o crime tipificado no artigo 35 "caput" da Lei 11.343/2006, fixo a pena privativa de liberdade em TRÊS (03) ANOS E SEIS (06) MESES DE RECLUSÃO e a pena pecuniária em 817 (oitocentos e dezessete) dias-multa.

Saliento que os Réus não fazem jus a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4º da Lei n. 11.343/06, levando em conta a quantidade e variedade da droga apreendida, bem porque faziam do tráfico meio de vida.

Veja-se, aliás, que se deve levar em conta a forma de acondicionamento de droga apreendida, característico do tráfico contumaz.

DECIDO.

Posto isso e, considerando tudo o que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação Penal, promovida pela Justiça Pública, para:

A) declarar o acusado CARLOS ANDRÉ DE OLIVEIRA ROSA, como incurso nas penas do artigo 33 "caput", c.C. O artigo 40, inciso IV (emprego de arma de fogo) da Lei 11.343/2006 e, em consequência, CONDENÁ-LO a CINCO (05) ANOS E DEZ (10) MESES DE RECLUSÃO e ao pagamento da pena pecuniária que fixo em 583 (QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS), DIAS-MULTA;

A-1) declarar o acusado CARLOS ANDRÉ DE OLIVEIRA ROSA, como incurso nas penas do artigo 35 "caput", c.C. O artigo 40, inciso IV (emprego de arma de fogo) da Lei 11.343/2006 e, em consequência, CONDENÁ-LO a TRÊS (03) ANOS E SEIS (06) MESES DE RECLUSÃO e ao pagamento da pena pecuniária que fixo em 817 (OITOCENTOS E DEZESSETE), DIAS-MULTA ;

B) declarar o acusado SANDRO WALLACE SILVA MACHADO como incurso nas penas do artigo 33 "caput", c.C. O artigo 40, inciso IV (emprego de arma de fogo) da Lei 11.343/2006 e, em consequência, CONDENÁ-LO a CINCO (05) ANOS E DEZ (10) MESES DE RECLUSÃO e ao pagamento da pena pecuniária que fixo em 583 (QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS), DIAS-MULTA E

B1) declarar o acusado SANDRO WALLACE SILVA MACHADO como incurso nas penas do artigo 35 "caput", c.C. O artigo 40, inciso IV (emprego de arma de fogo) da Lei 11.343/2006 e, em consequência, CONDENÁ-LO a TRÊS (03) ANOS E SEIS (06) MESES DE RECLUSÃO e ao pagamento da pena pecuniária que fixo em 817 (OITOCENTOS E DEZESSETE), DIAS-MULTA.

ABSOLVER os acusados, já qualificados, do delito tipificado no artigo 16, § 1º, inciso IV da Lei nº 10.826/03.

REGIME CARCERÁRIO:

Considerando as circunstâncias judiciais do art. 59, conforme antes examinado, do Código Penal, § 3º, do artigo 33, do mesmo Diploma Penal, à luz do artigo 110, da Lei 7.210/84, ante a nova redação do §1º, do inc. II, do art. 2º, da Lei 8.072/90, que apesar do art. 1º, inc. I, segunda parte, do mesmo Dispositivo, considerar crime comparado a hediondo o tráfico de entorpecentes, estabelece que a pena deve ser cumprida em regime inicialmente FECHADO, de acordo com Lei n. 11.464, de 28 de março de 2007, então, os cumprimentos das penas se darão dessa forma, obviamente ressalvada a competência do Juízo da Execução, na forma do art. 66 da Lei de Execuções Penais.

Quanto ao que preceitua o art. 387, §2º do CPP, deixo de aplicar neste momento. Isso porque, considerando, o teor do art. 2º, da Lei dos Crimes Hediondos (Vide Súmula Vinculante) (Redação dada pela Lei nº 11.464, de 2007), que diz no § 1º que a pena será cumprida inicialmente no regime fechado, independe do quantum fixado (diferente dos crimes comuns), nada há o que se falar em, dado esse tempo da cautelar, de modificação do regime.

A doutrina de G. de Souza Nucci diz que não se trata de um juízo de execução, o qual haverá de ser feito pelo juiz competente no VEC .

Vale dizer, conforme a mesma doutrina, a autorização legislativa é para um exame, quero crer, similar ao de detração, MAS APENAS para verificar o quantum de pena que resta do montante fixado em condenação e assim para observar, se nos termos do art. 33 do Código Penal, o resultante fica inferior a determinado tempo (número de anos), quando não sendo o condenado reincidente e reunidas condições judiciais favoráveis como diz o Código (arts. 59 e 60), pode receber regime mais brando do que indicaria o total inicial absoluto fixado, ou seja, seria, por exemplo,

passível um condenado a pena inferior a 8 anos (nesse caso mesmo que superior, descontado o tempo da cautelar, se assim resultasse inferior a 8 anos, aliás, como foi o exemplo doutrinário, se caberia, a critério do magistrado, o regime mais brando, mas não neste que é regime inicial fechado independente da pena, como visto).

Já detração propriamente e progressão, só pode ocorrer na VEC pelo juiz competente que a tudo observará (méritos do condenado, contraditório e etc.).

Assim, reservo, conforme a Lei, o exame imediato quanto a isso àquele Juízo, sendo que já será pelo cumprimento dos, em tese, 2/5 ou 3/5 da pena - hediondo - (examinando sobre o comportamento carcerário do condenado e o juízo de progressão/merecimento), pois seria temerário conceder neste momento, em crime que exija o regime mais gravoso, a quem não o mereça pelo eventual mau comportamento, aliás, e se fosse nessa extensão, os poderes do juiz do conhecimento deveriam ser realmente dilargados para a detração e progressão mesmo e ele careceria, ainda, de elementos pelo Estado para a plena aplicabilidade na prática dessa possibilidade, ou seja, a criação de um sistema de consultas on-line para no momento da sentença observar-se eventual falta grave do Réu preso provisório durante a cautela (modo contrário, correria o magistrado risco de, repiso, conceder algo que redunde na soltura imediata do condenado que, por exemplo, tenha liderado rebelião ou mesmo atacado colegas de cela em clara demonstração de abominável comportamento carcerário).

Veja-se decisão no TJSP confirmando entendimento, recurso de decisão deste mesmo prolator:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA PODER JUDICIÁRIO São Paulo Apelação n. 0009028-

26.2014.8.26.0220 - Guaratinguetá - VOTO N. 30.286 - RELATOR IVAN SARTORI:

"...Por derradeiro, o pedido de detração, com vistas a regime mais brando, é matéria a ser apreciada pelo Juízo das Execuções Criminais, pese o disposto na Lei 12.736/12, que acresceu o § 2º ao art. 387 do CPP. É que, para progressão de regime, necessário bem avaliar os requisitos pertinentes, sem falar na possibilidade de supressão de um grau de jurisdição, em ofensa a princípio constitucional. Nessa linha, julgados desta Casa de Justiça: "(...) embora não se desconheça o teor da Lei n. 12.736/2012, que acrescentou o § 2º ao artigo 387, do Código de Processo Penal, estabelecendo que o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade, infere-se inviável, de igual sorte, a alteração do regime prisional, na hipótese, com esteio no lapso que perdurou a prisão cautelar, porque não se tem notícia a respeito da real situação carcerária dos recorrentes, isto é, se não registram outras condenações ou prisões processuais nem quanto aos seus comportamentos e condutas no cárcere, a revelar não existirem elementos seguros para a correta análise, nesta seara e de pronto, quanto a eventual direito à detração penal, emergindo mais adequado que o juízo da execução se manifeste por primeiro, à mingua de informações concretas e, sobretudo, em estrita obediência ao princípio constitucional do duplo grau de jurisdição (...)." (Apelação n. 0009573-71.2012.8.26.0348, 5ª Câmara de Direito Criminal, rel. Juvenal Duarte, j. 13.02.2014); "(...) com relação à detração penal, tem-se que o Juízo de origem ainda não conheceu desta questão. Por esta razão, não se pode, nesta Instância Judicial, suprimir-se, de uma só vez, o devido processo legal (cf. artigo 5º, inciso LIV, da Constituição Federal), a manifestação do Juiz Natural (cf. artigo 5º, inciso LIII, da CF) e a garantia ao duplo grau de jurisdição (cf. artigo 5º, inciso LV, da CF), sob pena de vilipêndio à Lei Maior do País. Tudo recomenda, decerto, que se aguarde a decisão a ser produzida no Juízo das Execuções até porque continua vigente o artigo 66, inciso III, alínea 'c', da Lei 7.210/1984, a par do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, inserido pela Lei 12.736/2012 quando já presentes informações precisas para o exame com a minúcia necessária da situação prisional do acusado, para que repercuta na fixação do regime carcerário" (Apelação n. 0078884-36.2012.8.26.0224, 7ª Câmara de Direito Criminal, rel. Roberto Solimene, j. 06.02.2014). Em suma: mantém-se o r. édito monocrático, encampada sua motivação (art. 252 RITJ). Ivan Sartori - Desembargador Relator"

SUBSTITUIÇÃO DA PENA:

Originariamente não se apresentava possível a substituição da restrição da liberdade imposta por quaisquer penas restritivas de direito, já que em crimes da espécie a lei especial vedava expressamente, mas foi suspensa pelo Senado esta parte após julgamento no STF. Ipsis litteris: § 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. (Vide Resolução n. 5, de 2012)

Porém, não se apresenta possível a substituição da restrição da liberdade imposta por quaisquer penas restritivas de direito devido à quantidade de pena, que se resultou superior a 04 (quatro) anos (art. 44, I do Código Penal).

SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA:

Pelo quantum da pena imposta, impedida a obtenção do benefício (art. 44, da lei 11.343, de 23 de agosto de 2006 e 77, do Código Penal).

DIREITO DE RECURSO EM LIBERDADE:

Considerando que os Réus responderam a todo o processo presos, assim continuarão, conforme é o entendimento correntio da jurisprudência nacional, sendo muito possível que uma vez soltos voltem ao tráfico ou até fujam do distrito da culpa, dificultando ou impedindo o cumprimento da pretensão executória estatal.

Expeçam-se Mandados de Prisão, portanto, contra os condenados para cumprimento na prisão em que se encontram.

Após o trânsito em julgado lance-se os seus nomes no Rol dos Culpados (artigo 5º, inciso LVII, da Constituição da República) e Oficie-se a Justiça Eleitoral.

Custas "ex-lege"

P.I.C

Walter Emídio da Silva

Juiz de Direito